



刑事訴訟法

「当事者主義」

九州大学教授
田淵浩二
TABUCHI Koji



刑事訴訟の基本構造

訴訟において各主体が果たすべき役割や責任の関係性を訴訟構造という。「当事者主義」は多義的な概念であるが、一括すれば、訴訟目的を果たすために裁判官との関係で当事者の役割を重視する構造をさす。これに対し、当事者より裁判官の役割を重視する構造を「職権主義」という。両概念の対置は刑事訴訟の問題関心を反映している。以下では、刑訴においてなぜ訴訟構造論が活発化し、どう展開したかに焦点を当てた解説を行う¹⁾。

当事者主義と職権主義の対置は、近代刑事訴訟が「糾問主義」から「弾劾主義」へと変革した歴史が関係する。ローマ法の強い影響下にあったヨーロッパ大陸諸国では、中世から近世にかけて、裁判所が犯罪の嫌疑のある者を呼び出し、非公開の場で糾問官が自白を追求する糾問主義が登場し普及した。糾問手段として一定条件下で拷問も行われた。やがて人権思想が高揚し拷問は廃止され、自白を特別視する訴訟の維持は困難になった。そこで、弾劾主義のイギリスをモデルに、審判者と訴追者の役割を分離し、訴追者に被告人の刑事責任を立証させ、裁判所が自由な心証により罪を認定する構造へと変革する。しかし、裁判所を審判者としての役

割に徹底させず、実体的真実を発見する義務を課す、職権主義構造が残った。これに対し、ローマ法の影響をあまり受けなかったイギリスは、一般事件においては弾劾形式の陪審裁判が行われてきた。初期の陪審員は証人も兼ねており、自ら有する事件の知識に基づき裁判を行っていたが、やがて審判者の役割に純化される。陪審制の下でも長い間、被告人の弁護人を付す権利や証人喚問権は認められていなかったが、憲法や法律で被告人の防御権を保障するようになり、公判廷における当事者間の攻防を通じて勝敗を決める、当事者主義構造が形成される。このように歴史的には、当事者主義は自由主義的、職権主義は権威主義的思想に根差した訴訟構造といえる。判決の正当性にとって手続的公正をより重視する考え方が当事者主義であり、実体的真実への接近をより重視する考え方が職権主義であるという言い方もできるだろう。もっとも、現在のヨーロッパは欧州人権条約を介して、国の訴訟構造の違いを超えて公正な手続による裁判を受ける権利の標準化が進んでいる。



日本の刑事訴訟の構造

現行刑訴は、日本国憲法施行翌年の1948年に、新憲法に適合する民主的制度に改めること、及び英米法に倣い訴訟を当事者主義化することを目的に制定された。旧法下では、公判は弾劾形式であったものの、起訴後の予審において糾問的な審理を行い、その結果に基づき職権的に進行していた。これに対し、現行法は予審を廃止し、また裁判官は予断を持たずに公判に臨み、そこでの当事者の主張立証に基づき事実を認定する、当事者主義に転換した。しかし、現行法には旧法からの継続性を意識した条文も残った（例えば、刑訴298条2項・304条・311条2項〔以下刑訴略〕）。当事者主義を象徴する交互尋問制度は定めず、運用に委ねた（1957年刑訴規則改正によりルール化）。現行法の立案に関与した横井大三は、改正法の基本観念が如何なるものかは今後の議論次第であることを留保した上で、職権主義と当事者主義の長所をとって新しい一つの刑事手続の形態を示すことへの期待も含まれていたことをほのめかしている²⁾。

1) 笹倉宏紀「当事者主義」法教376号（2012年）4頁、青木孝之「現行刑事訴訟法における当事者主義」一橋

法学15巻2号（2016年）557頁による解説も合わせて参照されたい。

また、実体的真実主義を原理とする刑訴理論の体系を築いた団藤重光は、現行法は実体的真実主義に奉仕する手段として当事者主義を取り入れたのであって、その背後には職権主義が潜んでおり、補足的であるが必要なときはそれを発動できるようになっているという、**技術的当事者主義**を説いた³⁾。このように現行法は当事者主義への転換を図ったとはいえ、制定時はまだ職権主義と親和的な実体的真実主義の考え方が強かった。

ところで、民事訴訟においては、当事者間の「和解」又は原告による「請求の放棄」若しくは被告による「請求の認諾」を調書に記載したときは、その調書には確定判決と同一の効力が生じる（民訴267条1項）。私法の基本原則である「私的自治の原則」によれば、訴訟による解決も当事者の意思を尊重すべきだからである。この意味での当事者主義を（**当事者**）**処分権主義**という。これに対し、刑事法に私的自治の原則は妥当しないから、刑訴は処分権主義とは無縁に思うかもしれない。ところが、英米の刑事訴訟には「アレインメント」（arraignment）という制度がある。これは、被告人が有罪答弁（plea of guilty）をすれば事実審理を飛ばし有罪として、量刑審理のみを行う制度である。裁判官は根拠のない有罪答弁を受理しないこともできるが、被告人に一種の処分権を認める制度と見てよい。現行法の立案過程ではアレインメントの導入も論点となったが憲法38条3項（自白の補強法則）との関係で見送られたとされる⁴⁾。ところが、憲法38条3項のいう自白に公判廷自白は含まれないというのが後の判例であり⁵⁾、当該憲法規定は障害にならないから、実体的真実主義との整合性がアレインメントを導入しない唯一の理由たりうる⁶⁾。しかし、現在は実体的真実主義を絶対視する意見はなく、アレインメント導入論は今も続いている⁷⁾。



当事者主義の理論化

訴訟構造が当事者主義であることは、必ずしも当事者の訴訟上の権利が最大限に尊重されることを約束しない。当事者に認められた権利であっても、その効力の解釈には真実の解明や手続コストの考慮が加わるからである。これに対し、当事者の訴訟上の権利を当事者主義の意義にとって本質的な権利として説明できるならば、その効力の解釈において当事者の意思を最大限尊重させることが可能になる。この意味での「当事者主義の理論化」に成功した領域に、審判対象論がある。

審判対象の設定も含め、刑事訴訟における主張・立証は当事者の責任において行うべきとする考え方を、**当事者追行主義**という。現行法は英米法に倣い、起訴状に「訴因」を明示させる制度を導入した（256条3項）。訴因制度は当事者追行主義に関わる制度である。旧法下では、刑事訴訟の審判対象は起訴された歴史的社会的事実（旧法時代から「公訴事実」と呼ばれていた）であり、裁判所は公訴事実の同一性がある範囲で真実を解明する義務を負うと解されていた。そこで、実体的真実を重視する立場からは、現行刑訴の審判対象も公訴事実とした上で、訴因は罰条と合わせて犯罪事実の法律構成を示させ、防御上の便宜を図ったものに過ぎないとの解釈論も唱えられた⁸⁾。これに対し、平野龍一は、訴訟追行過程を当事者と裁判所のいずれの責任とするかが訴訟構造を性格付ける決定的部分であるとの理由から、「審判対象は検察官の設定した訴因である」とする訴因説を唱えた⁹⁾。そして判例も、概ね訴因説に従い訴因の特定や変更に関する論点に対応してきた¹⁰⁾。訴因説によれば裁判所は訴因を逸脱して審判する権限を持たないが、確定判決の効力は「公訴事実の同一性」（参照、312条1項）の範囲に及

2) 横井大三「改正刑事訴訟法概観」法時20巻9号（1948年）4頁。

3) 団藤重光「新刑事訴訟法と当事者主義」法時20巻9号（1948年）11-12頁、同「職権主義と当事者主義」日本刑法学会編『刑事法講座(5)刑事訴訟法(1)』（有斐閣、1954年〔再版〕）942頁。

4) 横井・前掲注2)8頁。

5) 最判昭和22・11・29刑集1巻40頁、最大判昭和22・12・19判タ1輯14頁、最判昭和23・2・12刑集2巻2号80頁。

6) 団藤・前掲注3)法時20巻9号11頁。

7) 参照、田口守一『刑事訴訟の目的（増補版）』（成文堂、2010年）第4章。

8) 参照、岸盛一「新刑訴は生かされているか——事実審の運用面からみた新刑訴法の判例」法時28巻3号（1956年）60頁。

9) 参照、平野龍一『刑事訴訟法の基礎理論』（日本評論社、1964年）20頁。訴因説の完成形は、同『刑事訴訟法概説』（東京大学出版会、1968年）86頁以下において提示される。

10) 参照、寺崎嘉博「当事者主義と訴因制度」法教245号（2001年）24頁。

ぶことになる。それゆえ、検察官が犯罪事実の一部起訴を行う場合、訴因に含めなかった犯罪事実については民訴のいう「請求の放棄」を行うのと等しい。この限りでは訴因説は検察官に事件の処分権を認める見解でもある¹¹⁾。

職権主義の下では、裁判所は真実の解明のために必要な証拠を職権で取り調べる義務を負い、義務を怠れば手続は審理不尽の法令違反となる。これに対し、当事者追行主義の下では、証明の責任は当事者が負うため、職権の不行使が直ちに審理不尽とはならない¹²⁾。なお、職権主義のドイツでは裁判所が事案説明義務を負うだけでなく、裁判官が早すぎる有罪確信により証拠調べを打ち切ることを防ぐために、当事者の証拠調べ請求にも強い権利性を認めている¹³⁾。この点、日本の刑訴法は予断排除の原則を採用しており、裁判官は予断を持たずに公判に臨むため、当事者の証拠調べ請求（298条1項）を事実上尊重せざるを得ない構造になっている。しかし、裁判官が事実を認定する以上、早すぎる有罪確信により証拠調べが打ち切られる危険はある。ところが、裁判所が当事者の証拠調べ請求を単に「必要性なし」と述べるだけで却下しても適法とされてきた。これでは、当事者が請求した証拠調べは裁判所の裁量次第ということになってしまう¹⁴⁾。証拠調べの範囲との関係では当事者主義の理論化は不完全なままである。

IV 当事者主義論の展開

当事者主義が機能するためには、両当事者が対等に攻撃・防御できなければならない。ところが、強制捜査を利用できる検察官は被告人・弁護人よりも証拠収集能力に優れており、ただ形式的に被告人に防御機会を与えても、実質的に公正な手続とは言えない。そこで、当事者主義には、被告人に検察官と実質的に対等な攻撃

防御手段を保障するべきとの意味も含まれており、とくに当事者対等主義または実質的当事者主義と呼ばれている¹⁵⁾。刑事訴訟における当事者の対等性は、検察官による弾劾に対して被告人側に有効な防御権を保障することにより達成できる。とはいえ、有効な防御のために必要な権利を対等性の概念から直ちに導き出せるわけではない。当事者対等主義のあいまいさが表面化した問題に、全面的証拠開示制度の導入の是非論がある。旧法時代は事件が公判に付された後、弁護人は裁判所で捜査記録の閲覧・謄写を行い、訴訟準備を行うことができた。しかし、現行法は起訴状一本主義を採用し、起訴状に捜査記録を添付することを禁止したため（256条1項・6項）、弁護人は検察官から捜査記録の閲覧・謄写をさせてもらって公判準備を進める必要が生じた。ところが、当初は当事者主義化を理由に検察官が捜査記録の任意開示を拒むこともあったという¹⁶⁾。現在は当事者対等主義の理念から、個別の根拠規定がなくても、検察官が証拠開示を義務付けられる場合があることは肯定されている¹⁷⁾。しかし、全面的証拠開示については消極論がなお有力である。被告人側が真実からではなく、検察官の手の内を知った上で捜査の弱い部分を突く主張を組み立てることになりかねないというわけである¹⁸⁾。そして現行法も、検察官請求証拠の証明力評価に直接関連しない証拠については、被告人の主張を待ってから、それに関連する範囲で開示する方式を採用している（316条の20）。

当事者主義は職権主義の対抗原理であって、刑事訴訟を職権主義に導く実体的真実主義の直接の対抗原理ではない。技術的当事者主義論が成り立つのはそれ故である。そこで、実質的当事者主義論は、実体的真実主義の対抗原理として憲法31条の適正手続の保障を据えるデュー・プロセス論へと展開していった。日本におけるデュー・プロセス論の第一人者となっ

11) なお、不起訴処分には確定判決と同じ効力は伴わない。

12) 例外的に、検察官が不注意で怠っている証拠の提出を促す義務が肯定された事例として、最判昭和33・2・13刑集12巻2号218頁。

13) 詳しくは、田淵浩二『証拠調べ請求権』（成文堂、2004年）。

14) なお、公判前・期日間整理手続終了後の証拠調べ請求や上訴審における証拠調べ請求の採否は、原則として裁判所の裁量に委ねられている（316条の32・393条1項）。

15) 参照、井戸田侃『刑事手続の構造序説』（有斐閣、

1971年）145頁以下。なお、欧州では欧州人権条約の定める「公正な裁判を受ける権利」から導き出される「武器対等の原則」として同様の議論が行われている（斎藤司「刑事手続における武器対等原則の意義とその適用可能性」法時84巻5号〔2012年〕46頁以下）。

16) 参照、佐伯千仞「崩壊しゆく人権保障〔特集・刑事裁判と人権〕」法時27巻6号（1955年）13-14頁。

17) 訴訟指揮権に基づく証拠開示命令が適法とされた事例として、最決昭和44・4・25刑集23巻4号248頁。

18) 参照、酒巻匡編著『刑事証拠開示の理論と実務』（判例タイムズ社、2009年）15頁以下、大澤裕「証拠開示制度」法時86巻10号（2014年）49-50頁。

た田宮裕は、憲法的刑事訴訟、司法の法形成機能、実質的当事者主義の三つが三位一体的に重なり合ったものを、デュー・プロセス論と名付けたと説明している¹⁹⁾。すなわち、憲法から出発し、裁判所が積極的に、当事者主義の実質化に向けた刑訴法解釈を展開すべきとの考え方が、デュー・プロセス論である。アメリカ連邦最高裁はとりわけウォーレン・コートの1960年代に、違法収集証拠の排除、弁護人の援助を受ける権利、自己負罪拒否特権、少年審判における公正な手続の保障等に関する憲法判例を次々と生んだ²⁰⁾。日本でもデュー・プロセス論を採用する判例はいくつか現れたが²¹⁾、どちらかという立法問題との判断にとどめることが多い。デュー・プロセス論は実質的当事者主義をある程度前進させたが、同時に、司法による法形成に期待することの限界も明らかにした。



当事者主義と捜査構造

当事者主義の実質化にとって捜査の構造も重要な意味を持つ。かりに捜査が糺問的に行われ、かつ捜査の結果が公判に強い影響を及ぼす構造になっていれば、公判を当事者主義化しても訴訟全体は半糺問的である。現行法はアメリカに倣って、捜査機関に強制捜査権限を付与した上で、裁判官が令状審査や証拠排除法則を通じて人権侵害的な捜査が行われないよう規律する方式を採用している。また、伝聞法則（320条）を採用し、捜査機関の作成した供述調書がそのまま証拠とならないようにしている。しかしながら、それにもかかわらず日米間の捜査の態様はかなり異なる。日本の検察官は、公判における有罪立証の確実性まで見通した上で、起訴・不起訴の決定を行っていると言われる。そのために、捜査段階において被疑者を取り調べ、供述を得ることが重視されてきた。これに対し、アメリカでは有罪立証を可能にする証拠を

集めることが捜査の目的であり、自白獲得に関心はあっても、被疑者の取調べは日本ほど重視されていない。こうした日米の捜査の考え方の違いは、「糺問的捜査観」と「弾劾的捜査観」と名付けられた²²⁾。

日本が糺問的捜査観から出発している理由は、戦前の予審と関係する。本来、予審制度の下では強制捜査は予審が担い、任意捜査により起訴に足りる証拠を集めることが起訴前捜査の役割となる。ところが、日本では旧法時代から起訴便宜主義の下での公訴権の運用のために、予審とは別に起訴前捜査が重視されていた。また、警察は強制捜査権限を持たなかったことから、行政検束や違警罪即処分を濫用して被疑者を拘束し、裁判官の統制が及ばないところで自白が追求された²³⁾。現行法が予審を廃止したのは、検察官と予審判事による二重捜査の非効率率や行政警察権限の濫用による人権侵害事例をなくすためであり、糺問的捜査を改めようという理由からではなかった。起訴独占・起訴便宜主義（247条・248条）の下での公訴権運用に予審の廃止による事件選別機能の一元化が加わり、現在の検察官は訴追官としての重い責任と権限を有している。旧法時代に胚胎した、検察官が強力な訴追権限を有する意味での当事者主義は、疑似当事者主義とも呼ばれている²⁴⁾。デュー・プロセス論は、疑似当事者主義を規律する方向ではほとんど成功していない²⁵⁾。



当事者主義と制度改革論

デュー・プロセス論は、アメリカの判例を参考にしつつ展開されてきた。しかし、日米の刑事司法制度はかなり異質な面もあり、法の共通面のみを捉えて同じ結論を引き出せるわけではない。そこで、アメリカとは異なり、犯罪の細部にまで拘った捜査や審理が行われる「精密司法」が日本の特色であることを踏まえた上で、何をどう是正すればよいかを議論することの必

19) 田宮裕『変革のなかの刑事法』（有斐閣、2000年）347頁。

20) 小早川義則「デュー・プロセス論の再構築」ジュリ1148号（1999年）80頁。アメリカのデュー・プロセス論の全容については、同『デュー・プロセスと合衆国最高裁Ⅰ～Ⅳ』（成文堂、2006年～2015年）。

21) 例えば、最大判昭和47・12・20刑集26巻10号631頁（迅速な裁判を受ける権利）、最判昭和53・7・10民集32巻5号820頁（接見交通権）、最判昭和53・9・7刑集32巻6号1672頁（違法収集証拠の排除）。

22) 平野龍一『刑事訴訟法』（有斐閣、1958年）83-85頁。

23) 参照、小田中聰樹『刑事訴訟法の歴史的分析』（日本評論社、1976年）450頁以下。

24) 松尾浩也『刑事訴訟の理論』（有斐閣、2012年）111頁。

25) 最決昭和55・12・17刑集34巻7号672頁は、検察官の訴追裁量の逸脱が公訴を無効にするのは、公訴の提起自体が職務犯罪を構成するよう極限的な場合に限定されるという。

要性が説かれるようになった²⁶⁾。また、アメリカでは通信傍受やおとり捜査が活用されており、日本でも組織犯罪対策のためにポスト・モダンの捜査手法を導入した上で、「全体的バランスの回復」²⁷⁾あるいは「逆説的調和」²⁸⁾の中で当事者主義の強化を果たすべきことが説かれるようになった。他方、弁護士がデュー・プロセスの担い手たるべきとの意識が高まり、1990年代に入り、日弁連を中心に刑事弁護体制の強化を目指した取組みが始まり、一定の進展があった²⁹⁾。こうした環境の変化の中、たまたま前世紀末から司法制度改革が政治課題となったことを機に、精密司法の因習から抜け出すための改革が動き出す（「精密司法から核心司法へ」

という標語が使用された³⁰⁾。その結果、2004年と2016年の法改正により、被疑者の国選弁護制度、公判前整理手続、裁判員制度、即決裁判手続、取調の録音・録画、協議・合意制度、刑事免責等の新制度が導入された。現在は、刑事裁判における取調べ調書の比重が低下し、公判審理は以前より活性化したと言われている。しかし、全ての取調の録音・録画の原則化、逮捕時からの国選弁護制度、取調の弁護人立会権³¹⁾などの当事者主義の実質化に向けた課題はまだ残っている。なおしばらく、当事者主義の実質化が改革の道標となることは間違いないだろう。

(たぶち・こうじ) 倉

26) 松尾・前掲注24)30-31頁、同『刑事訴訟法上〔新版〕』（弘文堂、1999年）16頁。精密司法論の評価について、大澤裕ほか「〔座談会〕松尾浩也先生を偲んで」論ジュリ27号（2018年）179-181頁、後藤昭「精密司法と疑似当事者主義」刑ジャ56号（2018年）28頁。

27) 田宮・前掲注19)18頁。

28) 松尾・前掲注24)374頁。

29) 参照、大出良知『刑事弁護の展開と刑事訴訟』（現

代人文社、2019年）。

30) 平野龍一「参審制の採用による『核心司法』を——刑事司法改革の動きと方向」ジュリ1148号（1999年）2頁、井上正仁「刑事訴訟法60年・裁判員法元年——序言」ジュリ1370号（2009年）2頁。

31) 詳しくは、川崎英明＝小坂井久編集代表『弁護人立会権——取調の可視化から立会いへ』（日本評論社、2022年）。